

0085124-05.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISADORA BOTTI BERALDO MORO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... torna, de per si, associados para o fim de cometimento do delito de tráfico de drogas, já que, se assim o fosse, todo e qualquer traficante seria denunciado e condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, posto que todos eles, ao fim e ao cabo, compram de alguém.

Ademais, o fato da clientela de EDGAR ter aumentado com a prisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0085124-05.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0085124-05.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 424/2017 - 38º Distrito Policial - Vila Amália

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RABACA VENDRAMINI e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO

Vistos.

ANDRÉ NUNES (pessoa falecida no curso do processo), EDGAR LUIS DA COSTA BUANI, THIAGO RABACA VENDRAMINI e MATHEUS DE ALMEIDA PRADO LITVIN, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso nos delitos descritos no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2018, nos termos da decisão de fls. 572/573.

Os réus foram devidamente citados (fls. 622, 623, 658 e 715) e apresentaram resposta à acusação.

Declarada extinta a punibilidade de ANDRÉ NUNES (fls. 956), diante da certidão de óbito de fls. 952.

Os autos foram distribuídos a esta especializada (fls. 1130).

Realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de 07 (sete) testemunhas de acusação e 06 (seis) testemunhas de defesa. Ao final, procedeu-se ao interrogatório dos acusados.

O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou alegações finais escritas, pugnano pela procedência parcial dos pedidos formulados na exordial acusatória, com a condenação dos réus apenas no delito tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

As defesas dos acusados apresentaram memoriais escritos (fls. 1569/1578, fls. 1582/1585 e fls. 1627/1632), pugnano pela absolvição dos réus.

É o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, como restou consignado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, não há que se falar no caso dos autos, da prática do delito previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, posto que não há prova nos autos de que cada um seja integrante de suposta organização criminosa. Ademais, não restou comprovado nos autos a satisfação dos requisitos e das elementares específicas que permitiriam a subsunção dos fatos narrados ao delito de organização criminosa.

Com efeito, não se denota da instrução processual qualquer prova segura o suficiente de que os denunciados eram componentes de uma organização criminosa, na qual ocupavam de modo estável funções hierarquicamente definidas, de modo harmônico e minimamente organizado, com atribuição fixa de funções e deveres.

Nos termos salientados pelo parquet, "afora a única menção ao 'primeiro comando da capital' feita por ANDRÉ em conversa telefônica, em que ele dizia que pediria autorização à facção, não há qualquer outro elemento indicativo de que os acusados integram aludida ORCRIM."

Isso porque a subsunção dos fatos a Lei nº 12.850/2013 demanda a verificação da existência de indícios suficientemente seguros da ocorrência dos elementos normativos previstos no art. 1º do mesmo Dispositivo Legal que concernem ao conceito legal de organização criminosa, o qual, após muita discussão doutrinária e jurisprudencial, é extraído do artigo 1º, § 1º, o qual, a seu turno, tem como raiz legislativa a Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado (Protocolo de Palermo Decreto n. 5.015/2004).

Assim, o fenômeno "organização criminosa" corresponde à "associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional".

Desta feita, de acordo com a própria tipificação legal, para configuração do conceito de organização criminosa, exige-se a satisfação dos seguintes requisitos objetivos: (i) a presença de 4 (quatro) ou mais pessoas; (ii) a verificação de uma estrutura ordenada; (iii) a divisão de tarefas entre os indivíduos componentes da referida estrutura, ainda que de maneira informal; (iv) a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagem de qualquer natureza; e (v) a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, a fim de obter as vantagens em questão.

Vê-se, portanto, que o delito de organização criminosa tem elementos normativos específicos e próprios que devem ser verificados concretamente para sua caracterização, os quais não foram demonstrados nestes autos, notadamente, com a segurança necessária à condenação dos acusados, a despeito de se equiparar a referida figura jurídica a mera ocorrência de concurso de agentes ou, ainda, ao delito de associação criminosa ou associação para o tráfico.

Nesta senda, note-se que estes possuem delineações próprias e requisitos que não se

confundem àqueles requeridos para caracterização do delito de organização criminosa. Isso porque o concurso de pessoas se verifica com a mera concorrência de mais de uma pessoa para o mesmo crime, ensejando a punição individual de cada uma delas na medida de sua culpabilidade, nos termos do art. 29 do Código Penal. A associação criminosa (antigo bando ou quadrilha), por sua vez, caracteriza-se com a simples associação entre 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes, não importando as penas máximas a eles cominadas, nos moldes do artigo 288 do Código Penal.

Sobre este aspecto, é de se destacar a lição de Cesar Roberto Bitencourt e Paulo Cesar Busato:

“Organização criminosa não é uma simples reunião de pessoas que resolvem praticar alguns crimes, e tampouco a ciente e voluntária reunião de algumas pessoas para a prática de determinados crimes, cuja previsão consta de nossos códigos penais, não passando do conhecido concurso eventual de pessoas (art. 29 do CP). (...) “Na verdade, organização criminosa não é uma associação qualquer, não é uma simples reunião de pessoas, ou uma mera associação para delinquir, como aquela prevista no art. 288 do CP, caso contrário, não seria necessária uma nova definição para esse badalado instituto jurídico” (BITENCOURT, Cesar Roberto, BUSATO, Paulo César. Comentários à lei de organização criminosa. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 26 e 28). Com efeito, a organização criminosa consiste em figura delitiva mais específica e que demanda a verificação de mais requisitos para a sua consumação, vez que é crime especial relativamente aos demais acima referidos. Assim, por certo que em toda organização criminosa haverá um concurso de pessoas ou mesmo uma associação criminosa, as quais consubstanciam figuras jurídicas mais simples e com menos requisitos objetivos para sua caracterização. Por consequência, a recíproca não é verdadeira.

E não é outra a conclusão a que conduz a análise dos requisitos objetivos exigidos para configuração da organização criminosa, por meio dos quais se deve diferenciar esta figura típica de qualquer outro conceito delitivo relacionado a reunião de agentes, notadamente aquele que concerne a verificação de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre os indivíduos, ainda de que maneira informal.

Exige o legislador, assim, um mínimo de organização hierárquica, estável e harmônica, com divisão de tarefas, vale dizer, com distribuição de funções e obrigações organizativas. Não é, portanto, qualquer concerto associativo que ostenta a necessidade de uma estruturação que se assemelhe a uma estrutura empresarial e que, por assim se constituir, consiga, por exemplo, mais agilidade nos negócios ilícitos.

Deste feita, na organização criminosa há um “planejamento empresarial” que é diametralmente oposto a um mero programa delinquencial, o qual confere a característica empresarial ilícita à organização e fomenta os negócios espúrios como, por exemplo, divisão de território, controle de pessoal, controle de fluxo de dinheiro, recrutamento de pessoas, planejamento de itinerários e rotas, divisão de funções e obrigações e até mesmo contato com autoridade e instituições. Assim, a característica marcante nesta estrutura empresarial ilícita concertada revela-se na hierarquia estrutural, representada por uma cadeia de comando que, ao fim e ao cabo, tem como objetivo melhor eficiência no atingimento dos objetivos do grupo. Além dos requisitos de natureza objetiva expressos, exige-se também que a organização criminosa tenha estabilidade e permanência, tal qual já era exigido para a quadrilha ou bando (hoje associação criminosa art. 288). Não basta uma mera reunião eventual de pessoas ou um simples ajustes de vontades, mas sim que a organização seja estruturalmente estável na prática de delitos que tragam algum tipo de vantagem.

Assim, tem-se que, não há prova nos autos capaz de condenar os réus como incursos no tipo penal do artigo 2º da Lei nº 12.850/13, sendo a absolvição pelo referido delito medida de rigor.

Contudo, seria o caso de condenação no delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06?

O referido artigo preceitua que comete o crime de associação para o tráfico aqueles

que associarem-se, em duas ou mais pessoas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34, do mesmo diploma legal.

Quanto ao artigo 35, é possível mencionar a necessidade de envolvimento mínimo de 02 (duas pessoas), da finalidade específica de cometer os crimes previstos nos artigos 33, caput e §1º, e 34, da Lei de Drogas e da desnecessidade da reiteração delitiva.

Contudo, é inegável que, apesar da desnecessidade da reiteração delitiva, é necessário um mínimo de animus associativo, com o objetivo de ser estável e duradoura, a ponto de ser mais do que um mero concurso de agentes.

No mesmo sentido, destaca-se tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: HC 235247/SP; no HC 270837/SP; no HC 286219/PE; no HC 271723/MG; no HC 260330/SP; no HC 137535/RJ; no HC 248844/GO; e no HC 239965/RJ.

Pois bem.

A testemunha AKHENATON AUGUSTO NOBRE SANTOS, delegado de polícia, disse em juízo que, a partir do recebimento de uma denúncia anônima, uma equipe policial começou a diligenciar no local. Salientou que observaram um sujeito com uma sacola e que tal sujeito, ao observar a movimentação policial, empreendeu fuga, dispensando a referida sacola, que continha drogas e um bilhete, com pedidos e números de telefone. Diante disso, foi realizada interceptação telefônica, que ensejou a prisão de MATHEUS. Com a continuidade das investigações, EDGAR e THIAGO foram presos na posse de entorpecentes. Segundo o delegado, as interceptações davam conta de que MATHEUS recebia muitos telefonemas de pessoas pedindo entorpecentes, sendo certo que, após sua prisão, EDGAR assumiu seu lugar. Ademais, mencionou que THIAGO era quem guardava as substâncias e que EDGAR se comunicava com ele para receber e distribuir drogas.

A testemunha ANDRE LUIZ HOFFMANN disse que apenas participou da prisão de ANDRE, oportunidade em que foram encontrados uma balança de precisão e 02 (dois) tijolos de maconha.

RAFAEL MOURA DA SILVA, policial civil, disse que participou apenas do cumprimento do mandado de prisão de EDGAR, salientando que local foi encontrada uma quantidade de maconha.

LEANDRO FREIRE DAMASCENO, policial civil, disse em juízo que receberam denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas e que participou da diligência inicial, que apreendeu drogas e um bilhete com telefones. Salientou que MATHEUS e EDGAR se comunicava para tratar da venda de drogas por ambos, sendo certo que, quando as drogas de EDGAR acabavam, ele solicitava mais a MATHEUS. Salientou que THIAGO ficava responsável pela guarda da droga para EDGAR. Contudo, disse não ter sido constatada durante a interceptação qualquer comunicação entre MATHEUS e THIAGO e ANDRÉ.

RUBENS FERNANDES DE MOURA, policial civil, disse que também participou da diligência inicial, que apreendeu drogas e um bilhete com telefones. Afirmou que foram captadas conversas entre MATHEUS e EDGAR e que, após a prisão de MATHEUS, EDGAR passou a receber mais telefonemas, inclusive de pessoas comentando acerca da prisão de MATHEUS.

Entendo que, após a instrução processual, com a colheita de provas em contraditório, não há como ter nos autos a certeza necessária de que os acusados praticaram o crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06.

Explico.

Apesar de ser notória a traficância, com a apreensão, inclusive, de substâncias ilícitas em poder dos acusados, não há como concluir que eles eram associados para tal fim.

É fato que eles se comunicavam. É notório, ainda, que um vendia drogas para o outro. É certo, também, que eles se conheciam. É comprovado que um passou a receber mais ligações telefônicas a respeito de entorpecentes após a prisão do outro.

Contudo, mesmo assim, não é possível concluir que há entre eles uma associação.

Eles não foram presos juntos. Eles não vendiam drogas juntos. Eles não manipulavam entorpecentes juntos. Eles não tinham uma forma de comercialização conjunta.

Além disso, o fato de MATHEUS, EDGAR, JORGE e TIOZINHO comparem a droga de um único

vendedor desconhecido, conforme organograma de fls. 345, não os torna, de per si, associados para o fim de cometimento do delito de tráfico de drogas, já que, se assim o fosse, todo e qualquer traficante seria denunciado e condenado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, posto que todos eles, ao fim e ao cabo, compram de alguém.

Ademais, o fato da clientela de EDGAR ter aumentado com a prisão de MATHEUS não é indicativo de associação entre eles, sendo capaz de demonstrar, apenas e tão somente, que o uso de drogas é imparável, que a política de combate ao tráfico de drogas é falida e que os usuários sempre vão encontrar na localidade o substituto daquele que foi preso.

Diante do exposto, pelo que consta dos autos, não é possível imputar aos acusados o delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo a absolvição medida de rigor.

Pelo exposto, e com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, e o faço para ABSOLVER EDGAR LUIS DA COSTA BUANI, THIAGO RABAÇA VENDRAMINI e MATHEUS DE ALMEIDA PRADO LITVIN dos delitos descritos no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

Sem custas.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA